

1500935-73.2021.8.26.0472

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... consigo, em um conhecido ponto de tráfico, 56 porções de "cocaína" com peso bruto de 40,0 gramas, 74 porções de "crack" com peso bruto de 13,0 gramas e 59 porções de "maconha" com peso bruto de 138,0 gramas.

Segundo narrou denúncia, "policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, um conhecido ponto de tráfico, quando um indivíduo se aproximou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

2ª Vara

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 525, . - Centro

CEP: 13660-017 - Porto Ferreira - SP

Telefone: (19) 3581-2201 - E-mail: portoferr2@tjsp.jus.br

1500935-73.2021.8.26.0472 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500935-73.2021.8.26.0472

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de PAULO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso no topo do artigo 33 da Lei 11.343/06 afirmando que em 15 de julho de 2021, por volta das 22h, na avenida Marginal 01, Bairro Paschoal Salzano, nesta cidade e comarca de Porto Ferreira, trazia consigo, em um conhecido ponto de tráfico, 56 porções de "cocaína" com peso bruto de 40,0 gramas, 74 porções de "crack" com peso bruto de 13,0 gramas e 59 porções de "maconha" com peso bruto de 138,0 gramas.

Segundo narrou denúncia, "policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, um conhecido ponto de tráfico, quando um indivíduo se aproximou da guarnição, sendo então abordado, tratando-se de Fábio César Canali, usuário de drogas que estava de passagem e nada de ilícito portava. Contudo, durante a abordagem a Fábio um dos policiais militares notou que havia outro indivíduo na mata próximo ao local, o qual, ao verificar a presença dos agentes, empreendeu fuga. O policial militar saiu então no encalço à procura do indivíduo, encontrando-o logo em seguida abaixado entre os arbustos, sendo identificado como o denunciado PAULO HENRIQUE, com o qual foi apreendida uma "pochete", objeto

comumente utilizado pelos traficantes, contendo as drogas acima indicadas e a quantia de R\$ 1.627,00 em moeda corrente fracionada. Formalmente interrogado (fl. 05), o denunciado confessou parcialmente sua participação no tráfico ocorrido no local, afirmando que foi até lá adquirir drogas para seu consumo e "... aceitou ficar cuidando do dinheiro do traficante em troca do pagamento no valor de duzentos reais e que enquanto cuidava do dinheiro os policiais surgiram de forma inesperada", negando que estivesse na posse das drogas também. Assim, as circunstâncias e local da prisão, a apreensão de considerável quantidade, variedade e a forma de acondicionamento das drogas, bem como de grande quantia em dinheiro proveniente do vil comércio e também a confissão, ainda que parcial, admitindo a participação no delito, demonstram, com segurança, que o denunciado trazia consigo os entorpecentes com a finalidade de tráfico."

A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico (finalidade da proteção penal) é a saúde pública.

No caso em exame, há prova da existência do crime e de sua autoria.

A existência do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 24/26), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 27/28), pelo laudo pericial (fls. 118/122) que resultou positivo para as drogas encontradas e, sobretudo, pela prova oral colhida. A autoria também é certa.

A testemunha comum, o policial militar Paulo Henrique da Silva, na fase policial, disse que "estava de serviço juntamente com o Pm Serra na Vtr I-38413 em patrulhamento pelo Bairro Paschoal Salzano, em local conhecido como ponto de venda de drogas, com o farol da viatura baixo a fim de coibir a traficância, quando um indivíduo desconhecido se aproximou, sendo de pronto abordado e identificado como Fabio Cesar Canali; que, efetuada revista pessoal no mesmo, nada de ilícito restou encontrado; que, indagado o que fazia no local, Fábio disse que é usuário e estava passando; que, neste interim, o depoente visualizou por entre a mata um indivíduo desconhecido, o qual ao verificar a abordagem saiu correndo; que, o depoente ficou observando e percebeu que o mesmo não havia atravessado a SP 215, ante o que resolveu procurá-lo; que, o depoente adentrou por entre os arbustos, e encontrou abaixada a pessoa identificada como PAULO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA, o qual trazia em sua cintura uma pochete que continha em seu interior 56 eppendorfs de Cocaína, 74 pedras de Crack, 59 porções de Maconha, fracionadas prontas para serem comercializadas, e a quantia de RS 1627,00 em moeda corrente fracionada; que, inquirido, Paulo Henrique confessou que estava praticando a Traficância e que iria ganhar RS200,00 por turno de serviço; que, o depoente não conhecia o indiciado Paulo Henrique Moreira da Silva, apenas Fabio Cesar Canali por abordagens anteriores em pontos de venda de drogas." Em juízo disse que viu duas pessoas; a segunda pessoa saiu correndo em meio aos arbustos; percebeu, no entanto, que a pessoa não tinha atravessado a rodovia, razão pela qual decidiu sair em seu encalço. Após encontrar o réu, fez a abordagem pessoal. Local é conhecido como "Biqueira da Mangueira". Drogas estavam separadas por tipos na pochete. Fábio servia o cliente, enquanto Paulo fornecia a droga. Fábio é gordinho e não consegue

correr. Após abordagem, Fábio foi deixado sentado na rua. Visualizaram os dois na rua antes da abordagem. Fábio teria se dito usuário de maconha, mas ele foi visto parado no local e não transitando. Não conhecia o réu de outras abordagens. Fábio já era conhecido.

A testemunha comum, o policial militar Ederson Luiz Mota Serra, na fase policial, disse que "estava de serviço juntamente com o CbPm Paulo Henrique na função de motorista da Vtr I-38413 em patrulhamento pelo Bairro Paschoal Salzano, em local conhecido como ponto de venda de drogas, com o farol da viatura baixo a fim de coibir a traficância, quando um indivíduo desconhecido se aproximou, sendo de pronto abordado e identificado como Fabio Cesar Canali; que, efetuada revista pessoal no mesmo, nada de ilícito restou encontrado; que, indagado o que fazia no local, Fábio disse que é usuário e estava passando; que, neste interim, Cb Paulo Henrique notou por entre a mata um indivíduo desconhecido, o qual ao verificar a abordagem saiu correndo; que, Cb Paulo Henrique foi procurar o mesmo, permanecendo o depoente na custódia do abordado inicialmente; que, Cb Pm Paulo Henrique veio a deter um indivíduo, identificado como PAULO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA, o qual trazia em sua cintura uma pochete que continha em seu interior 56 eppendorfs de Cocaína, 74 pedras de Crack, 59 porções de Maconha, fracionadas prontas para serem comercializadas, e a quantia de RS 1627,00 em moeda corrente fracionada; que, o mesmo foi indagado e confessou que estava praticando a traficância; que, o depoente não conhece o indiciado Paulo Henrique ou o investigado Fábio César." Em juízo disse que não conhecia o réu. Com o réu foram encontradas drogas (maconha, crack e cocaína) e dinheiro (quanta alta). Fábio disse ser usuário de drogas. Viu que o réu e Fábio estavam juntos, mas não avistou venda. Quando da abordagem viu que o réu saiu em direção ao matagal. Avistaram duas pessoas, mas não tem como afirmar que a segunda pessoa era o réu.

A testemunha comum Fábio César Canali, na fase policial, disse que "nesta data estava atravessando a via publica, quando foi abordado por Policiais Militares; que, o declarante foi revistado pelos Pms e nada de ilícito foi encontrado; que, um dos Pms adentrou a mata e apos alguns barulhos ouviu "perdeu, perdeu"; que, os Pms detiveram uma pessoa, cujo nome lhe é declinando como PAULO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA, o qual estaria de posse de uma pochete contendo drogas em seu interior e dinheiro; que, o declarante não conhece o detido, e não viu as circunstâncias da abordagem, ou como o entorpecente foi localizado; que, o declarante já teve passagem pela Policia pela Lei Maria da Penha, e nunca teve envolvimento com a traficância; que, o declarante passou por Exame de Corpo de Delito junto ao PSM local e não sofreu qualquer agressão quando de sua detenção ou na Delegacia; que, o declarante nega que tenha qualquer vínculo com o detido Paulo Henrique sendo apenas usuário de Cocaína e Crack, reafirmando que apenas atravessava a via quando de sua abordagem; que, o declarante conhece de vista o Pm Paulo Henrique." Em juízo manteve sua versão. No dia estava no bar; viatura o enquadrou e o mandou sentar no chão. Começaram a caçar na mata e voltaram com um moleque. Foi abordado na rua em frente ao bar (que estava aberto). É usuário de cocaína e crack. Não sabe se o local era um ponto de venda de drogas. Tomou uma dose no bar e ficou sentado ali de frente. Não conhece o réu. Não viu Paulo Henrique vendendo drogas. Não comprou drogas dele. Não se lembra ao certo, mas acha que o PM Paulo Henrique voltou após uns 10min. No bar havia algumas pessoas.

PAULO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA, em declarações perante a autoridade policial, disse que "é usuário de drogas, faz uso de cocaína e maconha, que na data de hoje foi até o local dos fatos comprar drogas, que o traficante do local lhe convidou para cuidar do dinheiro do trafico, que como está desempregado aceitou ficar cuidando do dinheiro do traficante em troca do pagamento no valor de duzentos reais, que enquanto cuidava do dinheiro os policiais surgiram de forma inesperada, que o declarante apenas se deitou ao solo obedecendo as ordens do policial, que apenas estava portando o dinheiro, que as drogas não foram encontradas em seu poder, que possivelmente foram deixadas pelo traficante que correu ao ver os policiais, que não conhece os policiais militares que o abordaram, que nega ter sofrido qualquer tipo de agressão tanto durante a abordagem quanto

durante o período que ficou nesta unidade policial; que, o interrogando já teve passagem anterior por Tráfico de Drogas, tendo ficado por três anos, três meses e treze dias." Em juízo disse ser inocente. Está sendo acusado em razão do local onde se encontra. Tem sua parcela de culpa. O local é um ponto de venda de drogas ("Biqueira da mangueira") e estava portando dinheiro lá. No dia 15/07 foi comprar um pino de cocaína; uma pessoa ofereceu R\$200,00 para ficar ali e o fez porque tem um irmão deficiente e precisava do dinheiro. Dinheiro estava no seu bolso. Pochete foi achada no meio do mato (distava uns 3m ou 4m), não estava na sua cintura. A pessoa que o contratou saiu correndo quando da abordagem policial. Conhecia essa pessoa só de vista. Acha que a pessoa que o contratou estava com medo de estar ali sozinho. Quando a viatura apareceu (estava no trio ao lado do condutor de energia), deitou-se próximo da torre de energia. Achava que os policiais não o tinham visto. Não viram a abordagem em Fábio. Acha que a pessoa que fugiu, ao perceber a viatura, jogou a droga no meio do mato, no local próximo onde depois foi se esconder. Droga não estava em sua propriedade, era de uma outra pessoa.

De início ressalto a impossibilidade de se aproveitar qualquer elemento derivado da suposta confissão informal feita pela pessoa acusada diante dos agentes de segurança do estado.

O STF, guardião da Constituição, já vem se pronunciando há tempos sobre o tema. O acórdão do RHC 122.279/RJ (rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 12/08/2014, DJe 30/10/2014) é instrutivo e vale a citação.

Conforme relatado, o recorrente teria furtado um telefone celular de um colega de caserna. Instaurado o Inquérito Policial Militar, foram inquiridas testemunhas. Durante a oitiva do recorrente (como testemunha), após afirmar versão diversa para os fatos, solicitou ao encarregado do IPM que fossem desconsideradas suas declarações e confessou o furto.

Recebida a denúncia e indeferido o habeas corpus no STM, o recorrente reafirma nesta Suprema Corte a ofensa ao princípio do nemo tenetur se detegere, assevera a nulidade da denúncia e pleiteia o trancamento da ação penal.

Evidentemente, a todos os órgãos estatais dotados de poderes normativos, judiciais ou administrativos impõe-se a importante tarefa de realização dos direitos fundamentais.

A Constituição Federal de 1988 atribuiu significado ímpar aos direitos individuais. Já a colocação do catálogo dos direitos fundamentais no início do texto constitucional denota a intenção do constituinte de emprestar-lhes significado especial. A amplitude conferida ao texto, que se desdobra em setenta e oito incisos e quatro parágrafos (CF, art. 5º), reforça a impressão da posição de destaque que o constituinte quis outorgar a esses direitos. A ideia de que os direitos individuais devem ter eficácia imediata ressalta, portanto, a vinculação direta dos órgãos estatais a esses direitos e seu dever de guardar-lhes estrita observância.

O constituinte reconheceu ainda que os direitos fundamentais são elementos integrantes da identidade e da continuidade da Constituição, considerando, por isso, ilegítima qualquer reforma constitucional tendente a suprimi-los (art. 60, § 4º). A complexidade do sistema de direitos fundamentais recomenda, por conseguinte, que se envidem esforços no sentido de precisar os elementos essenciais dessa categoria de direitos, em especial no que concerne à identificação dos âmbitos de proteção e à imposição de restrições ou limitações legais.

O direito ao silêncio, que assegura a não produção de prova contra si, constitui pedra angular do sistema de proteção dos direitos individuais e materializa uma das expressões do princípio da dignidade da pessoa humana.

Como se sabe, na sua acepção originária conferida por nossa prática institucional, este princípio proíbe a utilização ou a transformação do homem em objeto dos processos e ações estatais. O Estado está vinculado ao dever de respeito e proteção do indivíduo contra exposição a ofensas ou humilhações.

A propósito, em comentários ao art. 1º da Constituição alemã, Günther Dürig afirma que a submissão do homem a um processo judicial indefinido e sua degradação como objeto do processo estatal atenta contra o princípio da proteção judicial efetiva

(rechtliches Gehör) e fere o princípio da dignidade humana ["Eine Auslieferung des Menschen an ein staatliches Verfahren und eine Degradierung zum Objekt dieses Verfahrens wäre die Verweigerung des rechtlichen Gehörs."] (MAUNZ-DÜRIG, Grundgesetz Kommentar, Band I, München, Verlag C.H.Beck, 1990, 1/18).

O direito do preso – a rigor o direito do acusado – de permanecer em silêncio é expressão do princípio da não autoincriminação.

A Constituição Federal consagra expressamente o direito do preso de ser informado do seu direito de permanecer calado – art. 5º, LXIII.

No entanto, como ensina Paulo Mário Canabarro Trois Neto, o direito à não autoincriminação tem fundamento mais amplo do que o art. 5º, LXIII, da Constituição Federal. Em verdade, o direito é derivado da "união de diversos enunciados constitucionais, dentre os quais o do art. 1, III (dignidade humana), o do art. 5º, LIV (devido processo legal), do art. 5º, LV (ampla defesa), e do art. 5º, LVII (presunção de inocência)" (Direito à não autoincriminação e direito ao silêncio. Editora Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2011, p. 104).

Assim, é um direito aplicável não apenas no momento da prisão, mas permeia todo o processo penal.

Tal como anotado por Pertence em magnífico voto proferido no HC 78.708, de que foi o relator (DJ de 16-4-1999), "o direito à informação da faculdade de manter-se silente ganhou dignidade constitucional – a partir de sua mais eloquente afirmação contemporânea em Miranda vs. Arizona (384 US 436, 1966), transparente fonte histórica de sua consagração na Constituição brasileira – porque instrumento insubstituível da eficácia real da vetusta garantia contra a auto-incriminação – nemo tenetur prodere se ipsum, quia nemo tenere detegere turpitudinem suam –, que a persistência planetária dos abusos policiais não deixa de perder atualidade". Essas regras sobre a instrução quanto ao direito ao silêncio – as chamadas Miranda rules – hão de se aplicar desde quando o inquirido está em custódia ou de alguma outra forma se encontre significativamente privado de sua liberdade de ação: "while in custody at the station or otherwise deprived of his freedom of action in any significant way".

Assim como os Estados Unidos, os países democráticos em geral reconhecem o direito ao silêncio.

Na Alemanha, a despeito da ausência de previsão expressa na Lei Fundamental, é tido por derivado do estado de direito, da dignidade humana (artigo 1, I) e do direito ao livre desenvolvimento da personalidade (artigo 2, I) (DIAS NETO, Theodomiro. O direito ao silêncio: tratamento nos direitos alemão e norte-americano. Revista Brasileira de Ciências Criminais. v. 5, n. 19, p. 186. São Paulo: 1997). No plano legal, o artigo 136 do Strafprozeßordnung (StPO) – Código de Processo Penal – prevê que o implicado será prontamente advertido do direito de não fazer declarações.

Na Espanha, o art. 24.2 da Constituição prevê o direito de não declarar contra si ou confessar-se culpado.

Igualmente, o art. 38 da Constituição japonesa prevê que ninguém será compelido a testemunhar contra si.

Em nosso país, antes do advento do texto constitucional de 1988, o tema já era tratado entre nós no âmbito do devido processo legal, do princípio da não-culpabilidade e do processo acusatório.

Titular do direito é não só o preso, mas também qualquer acusado ou denunciado no processo penal.

A jurisprudência avançou para reconhecer o direito ao silêncio aos investigados nas comissões parlamentares de inquérito.

Destaco, também, que o direito ao silêncio tem uma repercussão significativa na ordem constitucional-penal como se pode depreender de alguns julgados do Supremo Tribunal Federal.

No HC 68.929, de 22-10-1991, da relatoria de Celso de Mello, asseverou-se que do direito ao silêncio, constitucionalmente reconhecido, decorre a prerrogativa processual de o acusado negar, ainda que falsamente, a prática da infração.

Desse, assim chamado, "direito de mentir" extraiu-se, também, a conclusão quanto à impossibilidade de se caracterizar a criminalidade da falsa negativa de reconhecimento pelo acusado de suas próprias assinaturas.

Na mesma linha, afirmou-se no HC 69.818, de 3.11.1992 (RTJ, 148/213), da relatoria de Sepúlveda Pertence, que, não obstante correto que à validade da “gravação de conversa pessoal entre indiciados presos e autoridades policiais, que os primeiros desconheceriam, não se poderia opor o princípio do sigilo das comunicações telefônicas”, seria invocável, na hipótese, o direito ao silêncio (art. 5º, LXIII), corolário do princípio nemo tenetur se detegere, “o qual, entretanto, não aproveita a terceiros, objeto da delação de coréus...x.

Questão mais complexa foi discutida no HC 78.708, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, no qual se alegou que acarretaria a nulidade das provas obtidas a omissão quanto à informação ao preso ou interrogado do seu direito ao silêncio no momento em que o dever de informação se impõe.

Da análise dos referidos julgados, podemos concluir que o direito à informação oportuna da faculdade de permanecer calado tem por escopo assegurar ao acusado a escolha entre permanecer em silêncio e a intervenção ativa. A escolha desta última importa, porém, ao acusado, a renúncia do direito de manter-se calado e das consequências da falta de informação oportuna a respeito.

Não há dúvida, porém, de que a falta da advertência quanto ao direito ao silêncio, como já acentuou o Supremo Tribunal, torna ilícita “prova que, contra si mesmo, forneça o indiciado ou acusado no interrogatório formal e, com mais razão, em 'conversa informal' gravada, clandestinamente ou não” (HC 80.949, rel. Sepúlveda Pertence, DJ de 14-12-2001).

Ainda sobre o tema, colho o estudo doutrinário de Aury Lopes Jr.:

“O direito de silêncio está expressamente previsto no art. 5º, LXIII, da CB (o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado (...)). Parece-nos inequívoco que o direito ao silêncio aplica-se tanto ao sujeito passivo preso como também ao que está em liberdade. Contribui para isso o art. 8.2, g, da CADH, onde se pode ler que toda pessoa (logo, presa ou em liberdade) tem o direito de não ser obrigada a depor contra si mesma nem a declarar-se culpada.

Ao estar assegurado o direito de silêncio sem qualquer reserva na Constituição e na Convenção Americana de Direitos Humanos, por lógica jurídica, o sistema interno não pode atribuir ao seu exercício qualquer prejuízo. (...)

(...) O direito de silêncio é apenas uma manifestação de uma garantia muito maior, insculpida no princípio nemo tenetur se detegere, segundo o qual o sujeito passivo não pode sofrer nenhum prejuízo jurídico por omitir-se de colaborar em uma atividade probatória da acusação ou por exercer seu direito de silêncio quando do interrogatório.

Sublinhe-se: do exercício do direito de silêncio não pode nascer nenhuma presunção de culpabilidade ou qualquer tipo de prejuízo jurídico para o imputado.

Como explica FERRAJOLI, o princípio nemo tenetur se detegere é a primeira máxima do garantismo processual acusatório, enunciada por Hobbes e recepcionada, a partir do século XVII, no Direito inglês. Dele seguem-se, como corolários, na lição de FERRAJOLI:

a) a proibição da tortura espiritual, como a obrigação de dizer a verdade; b) o direito de silêncio, assim como a faculdade do imputado de faltar com a verdade nas suas respostas; c) a proibição, pelo respeito devido à pessoa do imputado e pela inviolabilidade da sua consciência, não só de arrancar a confissão com violência, senão também de obtê-la mediante manipulações psíquicas, com drogas ou práticas hipnóticas; d) a consequente negação de papel decisivo das confissões; e) o direito do imputado de ser assistido por defensor no interrogatório, para impedir abusos ou quaisquer violações das garantias processuais”.

(Lopes Jr., Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 231-232).

Sobre a aplicação da norma de não autoincriminação, leciona Paulo Mário:

“O direito de não se autoincriminar surgiu e desenvolveu-se no bojo de transformações processuais pelas quais o imputado deixou de ser mero objeto da investigação e passou a ser tratado, simultaneamente, como sujeito do processo. No

arcabouço constitucional do Estado de Direito contemporâneo, seu caráter jusfundamental extrai-se do entrelaçamento das normas constitucionais da dignidade humana, do procedimento correto, da ampla defesa e da presunção de inocência. É por isso que a proteção contra a obrigatoriedade da autoincriminação constitui, hoje, um dos aspectos centrais sobre como o indivíduo deve ser tratado em uma determinada organização jurídico-social.

Adotada uma teoria ampla do tipo normativo, o direito de não se autoincriminar protege prima facie todos os comportamentos individuais passivos que se refiram a uma postura de seu titular, como parte processual não subordinada à parte contrária, de não colaborar para a própria condenação. Como mandamento a otimizar, esse direito pode colidir – e frequentemente colide – com bens coletivos constitucionais, com o princípio da busca da verdade. Essas colisões devem ser solucionadas mediante uma ponderação de bens, executada de acordo com os critérios de racionalidade, intersubjetividade e controlabilidade fornecidos pela teoria dos princípios e pela teoria da argumentação jurídico-constitucional. Embora o direito à não autoincriminação vá muito além da liberdade de declaração no interrogatório judicial, essa é uma das expressões mais importantes. Como estratégia de defesa passível de ser adotada pelo imputado, a opção pelo silêncio não é prova, meio de prova, nem sucedâneo de prova. Ainda que o comportamento de silenciar não admita valorações, a ausência objetiva de declarações pode, não obstante, constituir um elemento argumentativo do discurso das partes ou do juiz sobre a suficiência do material probatório. Se a formação do convencimento judicial deve ocorrer mediante procedimentos de confirmação e refutação da hipótese fática sustentada pela acusação, o silêncio do réu pode acarretar o desperdício de uma oportunidade de enfraquecer a tese acusatória ou de fortalecer uma tese defensiva incompatível com a afirmação da culpa do imputado. Como sujeito processual capaz de, com auxílio de seu advogado, conduzir-se autonomamente no exercício de sua defesa, o acusado é corresponsável pelo êxito de sua estratégia defensiva, e portanto deve exercê-la de modo consciente” (TROIS NETO, Paulo Mário Canabarro. Editora Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2011, p. 199-200).

O artigo 186 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 10.792, de 1º de dezembro de 2003, dispõe sobre o direito ao silêncio. Vejamos:

“Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas.

Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa” (grifo nosso).

Em comentário ao referido dispositivo legal, Guilherme de Souza Nucci considera:

“Direito do acusado ou indiciado ao silêncio: consagrado pela Constituição Federal de 1988, no art. 5º, LXIII, o direito de permanecer calado, em qualquer fase procedimental (extrajudicial ou judicial), chocava-se com a antiga redação do art. 186, em sua parte final, que dizia: 'O seu silêncio poderá ser interpretado em prejuízo da própria defesa'. A doutrina majoritária posicionava-se pela não recepção desse trecho do referido art. 186 pelo texto constitucional de 1988, embora alguns magistrados continuassem a utilizar desse expediente para formar seu convencimento acerca da imputação. Com a modificação introduzida pela Lei 10.792/2003, torna-se claro o acolhimento, sem qualquer ressalva, do direito ao silêncio, como manifestação e realização da garantia da ampla defesa” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 436) – (grifos nossos).

Em julgado mais recente sobre o tema, a Segunda Turma do STF, nos autos do HC 94.601/CE, de relatoria do ministro Celso de Mello, DJe 11.9.2009, voltou a reafirmar a necessidade de respeito ao direito ao silêncio, ressaltando que esse

privilégio contra a autoincriminação configura prerrogativa decorrente da cláusula do devido processo legal.
Eis a ementa desse julgado na parte em que interessa:

"A ESSENCIALIDADE DO POSTULADO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, QUE SE QUALIFICA COMO REQUISITO LEGITIMADOR DA PRÓPRIA 'PERSECUTIO CRIMINIS' .

- O exame da cláusula referente ao 'due process of law' permite nela identificar alguns elementos essenciais à sua configuração como expressiva garantia de ordem constitucional, destacando-se, dentre eles, por sua inquestionável importância, as seguintes prerrogativas: (a) direito ao processo (garantia de acesso ao Poder Judiciário); (b) direito à citação e ao conhecimento prévio do teor da acusação; (c) direito a um julgamento público e célere, sem dilações indevidas; (d) direito ao contraditório e à plenitude de defesa (direito à autodefesa e à defesa técnica); (e) direito de não ser processado e julgado com bases em leis 'ex post facto'; (f) direito à igualdade entre as partes; (g) direito de não ser processado com fundamento em provas revestidas de ilicitude; (h) direito ao benefício da gratuidade; (i) direito à observância do princípio do juiz natural; (j) direito ao silêncio (privilégio contra a auto-incriminação); (l) direito à prova; e (m) direito de presença e de 'participação ativa' nos atos de interrogatório judicial dos demais litisconsortes penais passivos, quando existentes".

No julgamento do HC 101.909/MG pela Segunda Turma do STF, relator ministro Ayres Britto, novamente, o respeito ao direito ao silêncio restou fortalecido:

"A Constituição Federal assegura aos presos o direito ao silêncio (inciso LXIII do art. 5º). Nessa mesma linha de orientação, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Pacto de São José da Costa Rica) institucionaliza o princípio da 'não-auto-incriminação' (nemo tenetur se detegere). Esse direito subjetivo de não se auto-incriminar constitui uma das mais eminentes formas de densificação da garantia do devido processo penal e do direito à presunção de não-culpabilidade (inciso LVII do art. 5º da Constituição Federal). A revelar, primeiro, que o processo penal é o espaço de atuação apropriada para o órgão de acusação demonstrar por modo robusto a autoria e a materialidade do delito" (DJe 19.6.2012).

Por todo o exposto, no presente caso, entendo assistir razão à defesa.
Conforme bem destacou a PGR, a denúncia apoiou-se unicamente na confissão do recorrente.
E essa confissão é inválida.

Como retratado no termo de inquirição (fl. 19), o soldado Arley foi ouvido inicialmente na condição de testemunha, sendo formalmente advertido do dever de dizer a verdade. Nesse momento, negou qualquer contribuição para o fato. No curso da inquirição, optou por confessar o crime. Constatou-se do termo:

"Até este momento o Sd Arley respondia às perguntas até que pediu para que o escrivão do presente Inquérito desconsiderasse tudo o que havia sido declarado, confessando que estava mentindo e, a partir de então, diria toda a verdade, enfatizando, inclusive, que foi ele mesmo, Sd Arley, que subtraiu o telefone celular."

Na sequência do termo, a confissão é detalhada.

Ou seja, houve um momento da inquirição em que, claramente, o inquirido manifestou a intenção de confessar o crime. Nesse momento, há uma mudança na relação do depoente com a investigação, passando da condição de testemunha à condição de suspeito.

Para validade das declarações subsequentes, a autoridade deveria ter respeitado, a partir de então, as regras do interrogatório. Ou seja, deveria ter advertido formalmente o depoente do direito ao silêncio. Isso não aconteceu - ou ao menos não foi registrado.

Portanto, tal declaração não tem valor por não ter sido precedida da advertência

quanto ao direito de permanecer calado.

Desse modo, acolhendo a manifestação da Procuradoria-Geral da República, voto no sentido de dar provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus para reconhecer a inépcia da denúncia, sem prejuízo de reapresentação, desde que a nova peça venha apoiada em outros elementos de prova. É como voto.

O entendimento continua sendo aplicado. Foi como decidiu a Suprema Corte recentemente no RHC 170.843 AgR/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 04/05/2021, DJe 01/09/2021. Com grifos nossos:

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravo da Procuradoria-Geral da República. 3. Condenação baseada exclusivamente em supostas declarações firmadas perante policiais militares no local da prisão. Impossibilidade. Direito ao silêncio violado. 4. Aviso de Miranda. Direitos e garantias fundamentais. A Constituição Federal impõe ao Estado a obrigação de informar ao preso seu direito ao silêncio não apenas no interrogatório formal, mas logo no momento da abordagem, quando recebe voz de prisão por policial, em situação de flagrante delito. Precedentes. 5. Agravo a que se nega provimento.

Digno de nota que todo o trâmite na fase policial deu-se sem qualquer referência de eventual advertência dos policiais militares que fizeram a abordagem acerca do direito ao silêncio da pessoa imputada.

Isso se torna especialmente grave quando se percebe que, enquanto garantia do cidadão frente ao estado, obviamente, cabe a este o ônus de provar o aviso do direito ao silêncio, sob pena de esvaziar o conteúdo da proteção constitucional. Ademais, se a acusação sustentar a existência dessa advertência do direito ao silêncio, caberá a ela provar também por força do 156 do Código de Processo Penal. Ora, não só não foi provado como também o estado-acusação entendeu ser possível desenvolver a persecução sem se preocupar sequer em mencionar o respeito a tal direito.

Além disso, de notar a diferença entre a versão do acusada declinada pelos policiais militares e aquela apresentada pela pessoa acusada momentos depois perante a autoridade policial civil.

Em relação à busca pessoal, o acusado estava em um ponto de venda de drogas, circunstância devidamente provada durante a instrução (PMs declinaram local já indicado em outros processos e o próprio réu confirmou que ali funcionava a "Biqueira da mangueira"), e se evadiu quando da aproximação dos policiais, o que permite concluir que havia justa causa para a diligência invasiva. Neste contexto é possível identificar uma fundada suspeita de que o agente estivesse na posse de objetos que constituam corpo de delito (em especial drogas), nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

Em relação ao mérito, embora tenha negado os fatos, a versão dada pelo acusado implicou, ao final, verdadeira confissão na modalidade coautoria (divisão de tarefas).

Além disso, sua versão de que o outro traficante arremessou a droga justamente no local onde ele na sequência foi se esconder da polícia não se mostrou crível. Apesar de haver no depoimento dos policiais uma incongruência em relação ao momento em que avistaram o acusado, tal imprecisão não tem o condão de contaminar aquilo que o é cerne da denúncia. A oscilação, tal como se deu, foi incapaz de afetar a credibilidade das testemunhas, até porque o réu em seu interrogatório ofereceu informações que se coadunam com a versão dos PMs.

Por todo o exposto, conclui-se com segurança que o réu trazia consigo as drogas apontas na denúncia.

Configurado, assim, o delito de tráfico de drogas, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

Passo a dosar as penas.

Primeira etapa. A pessoa acusada possui maus antecedentes (0003661-75.2013.8.26.0472), razão pela qual fixo a pena-base em seis anos e seis meses de reclusão, além de 650 dias-multa.

Não se aplica aos maus antecedentes o período depurador de cinco anos (Tema 150 da Repercussão Geral do STF - HC 593.818/SC).

Segunda etapa. Presente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência (certidão de antecedentes de fls. 49/51, autos 0001500-24.2015.8.26.0472). Conforme dispõe o art. 67 do Código Penal, a confissão só tem valor preponderante quando associada à personalidade do réu. No caso, a confissão foi feita sem qualquer demonstração de arrependimento resumindo-se à confirmação do já explicitado no flagrante, de modo que deveria prevalecer a reincidência com um aumento de 1/6 (um sexto). Todavia, tendo em vista a função constitucional dada ao STJ, principalmente na alínea "c" do inciso III do art. 105, e a consolidação do entendimento pela Terceira Seção, a qual reúne todos os ministros das turmas com competência criminal da corte, faço a compensação das circunstâncias e mantenho a pena no patamar indicado.

Terceira etapa. Ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena (impossível o redutor diante da reincidência).

Considerando o total de pena imposto e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial deverá ser, conforme orientação jurisprudencial, o fechado.

O regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, em razão da aferição negativa de circunstância judicial, que justificou o aumento da pena-base, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

STJ, HC 444200/RJ, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018.

O montante da pena privativa de liberdade exige o regime inicial fechado, impede a substituição por penas restritivas de outros direitos, bem como a sua suspensão condicional.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR PAULO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA à pena de reclusão, pelo prazo de seis anos e seis meses, em regime inicial fechado, bem como a 650 dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no topo do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Confirmando-se agora em cognição plena a existência do crime e sua autoria e não se apurando nada que infirme a periculosidade concreta do acusado, as razões de sua prisão cautelar estão mantidas.

3. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

(...)

5. A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes.

STJ, Sexta Turma, RHC 86.384/SP, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017.

Aliás, a custódia cautelar em casos análogos tem sido mantida pelos tribunais superiores:

3. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado.

4. Na espécie, a custódia cautelar foi mantida para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, caracterizada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas em poder dos agentes - cocaína (13 pinos), crack (53 pedras) e maconha (72 trouxinhas).

5. Ordem denegada.

STJ, Sexta Turma, HC 375559/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 22/11/2016, DJe 07/12/2016.

O tempo de prisão preventiva não autoriza, por hora, qualquer mudança em seu regime prisional.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado advogado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Declaro o perdimento de todos os valores e bens apreendidos em favor da União Federal, ainda que não se tenha comprovado a sua habitualidade na prática do tráfico, conforme artigo 63 da Lei n. 11.343/06, que regulamenta o parágrafo único do art. 243 da Constituição, e sua interpretação dada pelo pleno do STF. Todavia, por serem inservíveis e antieconômicos para a SENAD, determino a destruição ou doação dos seguintes bens: 01 POCHETE VERMELHA COM 6 BOLSOS.

Nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06 e Comunicado CG 2225/18, determino a destruição de eventuais amostras de entorpecentes guardadas para contraprova.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Ferreira, 26 de janeiro de 2022.

Valdemar Bragheto Junqueira - Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA